

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、勤務先の事務室で1人で残業をしていたところ、使用中の電気ストーブから周囲の可燃物に誤って引火させた。甲は、その時点での消火作業は容易であったにもかかわらず、同室を含む勤務先建物が焼損することを認容して、消火作業をすることなく、同室から立ち去り、その結果、同建物が全焼した。その行為当時、同建物の他の部屋では甲の同僚が仮眠中であり、甲もそのことを認識していた。この場合、甲に既発の火力を利用する意思がなければ、現住建造物等放火罪は成立しない。
- イ. 甲は、Vと2人きりのホテル客室で、その同意の下、Vに対し、覚醒剤を注射したところ、Vが体調の異変を訴え、錯乱状態に陥ったため、救急医療を要請する必要があることを認識し、その要請をしていれば、Vの救命は確実であったにもかかわらず、その要請をすることなく、Vを放置したまま同室から立ち去り、その結果、Vが死亡したが、甲に殺意はなかった。この場合、甲がVを放置した行為とVの死亡との間の因果関係に欠けることはなく、甲には、保護責任者遺棄等致死罪が成立する。
- ウ. 甲は、深夜、自動車を運転中、路上で過失により通行人Vに同車を衝突させて、歩行不能の重傷を負わせた上、一旦Vを同車に乗せて、降雪中の周囲にひとけのない路上に移動し、Vに対し、医師を呼んでくるとうそを言って、Vを同車から降ろし、同車で同路上から立ち去ったが、甲に殺意はなかった。この場合、甲には、Vを保護する責任があり、保護責任者遺棄等罪が成立する。
- エ. 甲は、自己の口座に振込先を誤った振込入金があったことを知ったが、銀行窓口において、窓口係員に対し、その受取人として上記の誤った振込入金があった旨を告知せずに、その払戻しを請求し、事情を知らない同係員をして、払戻しに応じさせた。この場合、甲には、上記の誤った振込入金があったことを告知する義務はなく、詐欺罪は成立しない。
- オ. 甲は、面識のない他人のVと口論に及び、その首を絞めて窒息死させ、Vの死体をその場に放置して逃走した。この場合、甲には葬祭義務はなく、死体遺棄罪は成立しない。

|        |      |     |     |     |     |     |     |
|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| No.440 | 不作為犯 |     |     |     |     |     | 正答率 |
| R3-9   | 正解   | ア 2 | イ 1 | ウ 1 | エ 2 | オ 1 | 53% |

## ア 誤っている

最判昭33.9.9（百選Ⅰ5事件）。不作為による放火の場合、大審院判例では、作為義務違反と並んで積極の利用意思が成立要件とされていた（大判大7.12.18、大判昭13.3.11）が、判例（最判昭33.9.9）は、本記述と同様の事案において、認識・認容という一般の故意の要件を挙げるのみで、現住建造物等放火罪（108条）の成立を認めており、既発の火力を利用する意思を要求していない。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、積極の利用意思を不作為犯の成立要件とするのは悪しき動機・心情を理由として処罰するものであり妥当でないということを挙げている。よって、本記述の場合、甲に既発の火力を利用する意思がなくても、現住建造物等放火罪は成立し得る。したがって、本記述は、甲に既発の火力を利用する意思がなければ、現住建造物等放火罪は成立しないとしている点で、誤っている。

## イ 正しい

最決平元.12.15（百選Ⅰ4事件）。本記述では、不作為犯における因果関係が問題となる。判例は、本記述と同様の事案において、「被害者の女性が被告人らによって注射された覚せい剤により錯乱状態に陥った午前零時半ころの時点において、直ちに被告人が救急医療を要請していれば、……十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると、同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められる」として、因果関係を肯定している。本記述では、甲が救急医療を要請していればVの救命は確実であったので、甲がVを放置した行為とVの死亡との間の因果関係に欠けることはない。よって、本記述の場合、甲には、保護責任者遺棄等致死罪（219条）が成立する。したがって、本記述は正しい。

## ウ 正しい

最判昭34.7.24。本記述では、甲が保護責任者といえるかが問題となる。判例は、本記述と同様の事案において、道路交通取締法（注：当時）違反（被害者救護義務違反）罪のほか要保護者遺棄罪〔現保護責任者遺棄罪〕（218条）が成立するとしている。その理由として、判例は、事故により人の殺傷があった場合、自動車操縦者は法令により救護義務を負うことから保護責任者といえること、また、218条の「遺棄」には単なる置き去りも含むところ、救護義務に必要な措置をとることなく被害者を自動車に乗せ事故現場を離れて降雪中の周囲にひとけのない路上に移動し、医師を呼んでくると言って、被害者を同車から降ろし、同車で同路上から立ち去ったことは「遺棄」に当たるということを挙げている。本記述の甲は、自動車を運転中、路上で過失により通行人Vに同車を衝突させて、歩行不能の重傷を負わせているので、Vの保護責任者といえる。よって、本記述の場合、甲には、保護責任者遺棄等罪が成立する。したがって、本記述は正しい。

## エ 誤っている

最決平15.3.12（百選Ⅱ52事件）。本記述では、誤振込につき告知義務違反があるとして、不作為による詐欺罪が成立するかが問題となる。判例は、本記述と同様の事案において、誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求し、その払戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立するとしている。その理由として、判例は、誤振込があった場合、銀行実務においては、振込依頼人からの申し出があれば組戻しという手続が、受取人からの指摘があった場合には自行の入金処理に誤りがなかったかの確認及び振込依頼人へ照会を行うなどの措置が講じられているところ、「これらの措置は、普通預金規定、振込規定等の趣旨に沿った取扱いであり、安全な振込送金制度を維持するために有益なものである上、銀行が振込依頼人と受取人との紛争に巻き込ま

れないためにも必要なものということができる。また、振込依頼人、受取人等関係者間での無用な紛争の発生を防止するという観点から、社会的にも有意義なものである。したがって、銀行にとって、払戻請求を受けた預金が誤った振込みによるものか否かは、直ちにその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であるといわなければならない。これを受取人の立場から見れば、受取人においても、銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として、自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には、銀行に上記の措置を講じさせるため、誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があると解される。社会生活上の条理からしても、誤った振込みについては、受取人において、これを振込依頼人等に返還しなければならず、誤った振込金額相当分を最終的に自己のものとするべき実質的な権利はないのであるから、上記の告知義務があることは当然というべきである」ということを挙げている。よって、本記述の甲には、誤った振込入金があったことを告知する義務があり、詐欺罪が成立する。したがって、本記述は誤っている。

## オ 正しい

大判大6.11.24。殺人後に死体を損壊した場合は死体損壊罪(190条)が成立し、死体を作為によって放置した場合は死体遺棄罪(190条)が成立する。これに対し、死体を不作為によって放置した場合、その死体に対する葬祭義務を有する場合に限り、死体遺棄罪が成立する。判例(大判大6.11.24)は、母親が新生児を砂中に埋めて窒息死させ、死体をそのまま放置した事案において、死体遺棄罪の成立を認めているが、殺害現場で死体の着衣を剥ぎ、全裸にしたまま放置した事案において、裁判例(福岡地飯塚支判昭40.11.9)は、同罪の成立を否定している。本記述の甲は、Vとは面識がなく、また、殺人を犯した者に埋葬等を期待することは困難であるから、葬祭義務はない。よって、本記述の場合、甲に死体遺棄罪は成立しない。したがって、本記述は正しい。

